

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 50/2535

นาย โกสุมภ์ ตาละโสภ ฌ
องค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศ ไทย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 421, มาตรา 537

ป.วิ.พ. มาตรา 142

จำเลยที่ 1 ให้บริษัท ส. ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในอาคารพาณิชย์ของบริษัท ด.เช่าโทรศัพท์ต่อมาบริษัทส. ย้ายออกไปและมอบเครื่องโทรศัพท์ให้บริษัท ด.ไว้บริษัทด. นำโทรศัพท์ดังกล่าวให้โจทก์ใช้โดยโจทก์นำค่าเช่าและค่าบริการไปชำระให้แก่จำเลยที่ 1 ตลอดมา ต่อมาจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 ได้ปลดพิวส์ งดมิให้ใช้บริการ เนื่องจากค้างชำระค่าเช่าและค่าบริการของงวดที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่โจทก์ใช้อยู่ประเด็นแห่งคดีมีว่าจำเลยที่ 3 ได้ทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มิใช่ผู้เช่าโทรศัพท์และเป็นบุคคลภายนอก เป็นการพิจารณาถึงสิทธิของโจทก์ว่ามีต่อจำเลยทั้งสามอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เห็นว่า การกระทำของจำเลยที่ 3ซึ่งทำให้โจทก์ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นั้นเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ทั้งเหตุที่ศาลอุทธรณ์ยกขึ้นมานี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ได้แย้งกันโดยตรงซึ่งจำเลยทั้งสามได้ให้การต่อสู้คดี ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นโจทก์มิได้ทำสัญญาเป็นผู้เช่าโทรศัพท์กับจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นแต่เพียงผู้ครอบครองและใช้โทรศัพท์โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ด. เจ้าของอาคารที่โจทก์เช่าตั้งสำนักงานประกอบกิจการอยู่เท่านั้น แม้โจทก์ชำระค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ให้

จำเลยที่ 1 ตลอดมา ก็ถือว่าโจทก์เป็นแต่เพียงมีสิทธิใช้โดยพฤตินัยเท่านั้น หาได้มีสิทธิผูกพันจำเลยที่ 1 ไม่ การที่โจทก์ชำระค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์เท่ากับเป็นการชำระแทนผู้เช่าเดิมและใช้โดยอาศัยสิทธิของผู้เช่าเดิมคือบริษัท ส. เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีนิติสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้หรือครอบครองโทรศัพท์กับจำเลยที่ 1 ในอันที่จำเลยที่ 1 จะต้องแจ้งให้โจทก์ทราบก่อนปลดฟิวส์ ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 ได้ส่งใบแจ้งเตือนให้ผู้เช่าตามที่อยู่ซึ่งให้ไว้ตรงตามสัญญาเช่าให้นำเงินไปชำระค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ที่ค้างชำระอยู่แก่จำเลยที่ 1 ครบกำหนดตามใบแจ้งเตือนแล้วผู้เช่าไม่นำเงินไปชำระ การที่จำเลยที่ 3 ขออนุมัติและทำการปลดฟิวส์ ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้กระทำการตามหน้าที่ และตามระเบียบของจำเลยที่ 1 แล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 ได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตสั่งระงับการใช้โทรศัพท์หมายเลข 2330567 ซึ่งโจทก์เป็นผู้ครอบครองและใช้ในการปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานกฎหมายโกสุมภ์และเพื่อนอาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ห้อง 1101 บี. โดยอ้างว่าโจทก์ค้างชำระค่าใช้บริการทั้ง ๆ ที่โจทก์ไม่เคยค้างชำระและจำเลยที่ 3 ระงับการใช้โทรศัพท์โดยมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบก่อนว่าจะต้องนำค่าใช้โทรศัพท์ที่ค้างไปชำระ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากลูกค้าของสำนักงานโจทก์ไม่สามารถติดต่อกับโจทก์ได้เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่ทราบนัดที่จะต้องไปศาลอย่างน้อย 3 คดี ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายคิดถึงวันฟ้องเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และขาดประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวคิดเป็นเงินวันละ 3,000 บาท จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามต่อสายโทรศัพท์หมายเลข 2330567 ให้โจทก์ใช้เช่น

เดิม และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายกับค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหาย
จากวันฟ้องแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์มิได้เป็นผู้เช่าโทรศัพท์หมายเลข 2330567 การที่
จำเลยที่ 3 ปลดฟิวส์ งดให้บริการใช้โทรศัพท์จึงไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์
นอกจากนี้โจทก์และจำเลยที่ 1 มิได้มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง
จำเลยทั้งสาม ก่อนที่จำเลยที่ 3 จะขออนุมัติปลดฟิวส์ งดให้บริการนั้นจำเลยที่ 3 ได้
ตรวจสอบหลักฐานพบว่า ผู้เช่าโทรศัพท์เลขหมายดังกล่าว คือบริษัทสายการบิน ที
ดับบลิว เอ จำกัด ดำงชำระค่าเช่า จำเลยที่ 3 จึงมีหนังสือทวงถามไปตามที่อยู่ใน
ทะเบียนติดตั้งเลขที่ 1-3 ศาลาแดง แต่ส่งให้ผู้เช่าไม่ได้โดยได้รับแจ้งว่าย้ายไปแล้ว
เมื่อครบกำหนดเวลาตามระเบียบ จำเลยที่ 3 จึงขออนุมัติปลดฟิวส์ จึงไม่เป็นละเมิด
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน
30,000 บาท ค่าขออื่นสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ให้ยกและให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 โจทก์
และจำเลยที่ 1 ที่ 3 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับ
จำเลยที่ 1 และที่ 3 ด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยทั้งสามนำสืบรับกันโดยไม่ได้
แย้งเป็นอย่างอื่นฟังได้เบื้องต้นว่า โจทก์ได้เช่าห้องของอาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ถนน
พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามพระราช
บัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ให้บริการเช่าโทรศัพท์ มี
จำเลยที่ 2 เป็นผู้อำนวยการและจำเลยที่ 3 เป็นเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ของจำเลยที่ 1
ประจำอยู่ที่ชุมสายสุรวงศ์เมื่อ พ.ศ. 2518 จำเลยที่ 1 ได้ให้บริษัทสายการบินที ดับบ

ลิว เอ จำกัด ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในอาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ทำให้สัญญาเช่าโทรศัพท์หมายเลข 2330567 ดังปรากฏตามสัญญาเช่าเอกสาร ล.8 ต่อมาบริษัทสายการบินดังกล่าว ย้ายออกไปจากอาคารพาณิชย์ดุสิตธานี และได้มอบเครื่องโทรศัพท์ให้บริษัทดุสิตธานี จำกัด ไว้บริษัทดุสิตธานี จำกัด จึงนำโทรศัพท์ดังกล่าวให้โจทก์ใช้โดยตอนแรกบริษัทจะออกค่าเช่าและค่าบริการแทนไปก่อนแล้วโจทก์จึงนำมาชำระให้แก่บริษัทครั้งนภายหลังจากโจทก์ได้นำค่าเช่าและค่าบริการไปชำระให้แก่จำเลยที่ 1 เอง และได้ติดต่อขอเป็นผู้เช่าโทรศัพท์แทนบริษัทสายการบินดังกล่าว จำเลยที่ 1 รับเรื่องไว้แล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการให้ระหว่างที่โจทก์ครอบครองและใช้โทรศัพท์อยู่ ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ตรวจพบว่าผู้เช่าโทรศัพท์ดังกล่าวยังค้างชำระค่าเช่าและค่าบริการประจำเดือนมีนาคม 2527 เป็นเงินจำนวน 628 บาท จำเลยที่ 3 จึงส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้เช่าไปพร้อมกับใบแจ้งหนี้ประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2528 ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.3 และ ล.9 (แผ่นที่ 2) โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ปรากฏว่าส่งให้ผู้เช่าไม่ได้ เพราะได้ย้ายไปแล้ว ทางพนักงานไปรษณีย์จึงส่งเอกสารดังกล่าวกลับคืนมาให้ดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 ต่อมาผู้เช่าได้นำเงินค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ไปชำระเฉพาะประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2528 เท่านั้น โดยไม่ยอมชำระที่ค้างประจำเดือนมีนาคม 2527 จนครบกำหนดเวลาที่แจ้งเตือนแล้วจำเลยที่ 3 จึงขออนุมัติปลดฟิวส์และทำการปลดฟิวส์งดมิให้ใช้บริการ โจทก์จึงใช้โทรศัพท์ดังกล่าวไม่ได้ ปัญหาสำคัญที่ควรวินิจฉัยเสียก่อนมีว่า การที่จำเลยที่ 3 ทำการปลดฟิวส์ระงับการใช้โทรศัพท์ที่โจทก์ใช้อยู่ นั้น เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตซึ่งเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาในข้อแรกว่าศาลอุทธรณ์พิจารณาโดยตั้งประเด็นขึ้นมาใหม่ว่า จำเลยที่ 3 ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่แล้วพิพากษาว่าโจทก์มิใช่ผู้เช่าโทรศัพท์ โจทก์เป็นบุคคลภายนอก การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นได้ตั้งไว้ และไม่เป็นประเด็นที่ได้แย้งกันมาแต่ศาลชั้นต้น จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาตรา 142 วรรคแรก และศาลอุทธรณ์ยังวินิจฉัยอีกว่าโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เช่าโทรศัพท์ ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 จึงเท่ากับวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ซึ่งศาลชั้นต้นไม่ได้ตั้งประเด็นไว้นั้น เห็นว่า ประเด็นแห่งคดีนี้มีอยู่โดยตรงแล้วว่า จำเลยที่ 3 ได้ทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มิใช่ผู้เช่าโทรศัพท์และเป็นบุคคลภายนอกนั้น เป็นการพิจารณาถึงสิทธิของโจทก์ว่ามีต่อจำเลยทั้งสามอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้เห็นว่าการกระทำของจำเลยที่ 3 ซึ่งทำให้โจทก์ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นั้นเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ทั้งเหตุที่ศาลอุทธรณ์ยกขึ้นมาวินิจฉัยนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ได้แย้งกันโดยตรง ซึ่งจำเลยทั้งสามได้ให้การต่อสู้และนำสืบมาแต่ต้นแล้ว และไม่ขัดกับที่ศาลชั้นต้นได้ตั้งประเด็นไว้ทั้งนี้เพราะการวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ย่อมเห็นได้ว่าได้นำสิทธิของโจทก์ที่โจทก์มีต่อจำเลยทั้งสามและพฤติการณ์แห่งคดีมาวินิจฉัยการกระทำของจำเลยที่ 3 ว่า เป็นละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ความรับผิดชอบละเมิดนั้นอาจเกิดแก่บุคคลใดที่ไม่ใช่คู่สัญญาก็ได้จึงไม่จำเป็นต้องมีนิติสัมพันธ์ต่อกันมาก่อนอย่างเช่นในกรณีของเอกเทศสัญญา และเรื่องนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องจำเลยเกี่ยวกับสัญญาเช่าแต่ฟ้องฐานละเมิด โจทก์จึงเป็นผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นั้น เห็นว่าการฟ้องฐานละเมิดอาจเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่มีสัญญาและไม่มีสัญญาซึ่งแล้วแต่ว่าการกระทำละเมิดนั้นเกิดขึ้นจากเหตุและกรณีใดเป็นเรื่อง ๆ ไป ทั้งนี้ต้องอาศัยพฤติการณ์แห่งคดีเป็นหลักและผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีฐานละเมิดนั้นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหาใช่เพียงแต่เป็นผู้เสียหายโดยพฤตินัยเท่านั้นไม่และบางกรณีต้องเป็นผู้เสียหายตามสัญญาที่ได้ทำไว้ต่อกันเท่านั้น บุคคลภายนอกแม้จะได้รับความเสียหายก็ไม่มีสิทธิฟ้องคดีได้ เพราะมิใช่เป็นการทำละเมิดต่อผู้นั้น ดังเช่นคดีนี้ ข้อเท็จจริงฟังยุติแล้วว่าโจทก์มิได้ทำสัญญาเป็นผู้เช่าโทรศัพท์กับจำเลยที่ 1 แต่การที่ผู้ใดจะมีสิทธิติดตั้งใช้โทรศัพท์จากจำเลยที่ 1 ต้องขอและได้รับอนุญาต แล้วทำสัญญาเป็นผู้เช่ากับจำเลยที่ 1 เสียก่อน จำเลยที่ 1 จึงจะจัดการติดตั้งให้เช่าใช้

โทรศัพท์ได้ เมื่อได้ทำสัญญาเช่าไว้แล้วมีการจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ฝ่ายใด ก็ถือได้ว่าการทำละเมิดเกิดขึ้นโดยนิตินัย แต่กรณีของโจทก์เห็นได้ชัดว่าเป็นแต่เพียงผู้ครอบครองและใช้โทรศัพท์โดยได้รับมอบหมายมาจากบริษัทอุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของอาคารที่โจทก์เช่าตั้งสำนักงานประกอบกิจการอยู่เท่านั้น แม้โจทก์ได้ชำระค่าเช่า และค่าบริการโทรศัพท์ให้จำเลยที่ 1 ตลอดมาก็ถือว่าโจทก์เป็นแต่เพียงมีสิทธิใช้โดยพุดินัยเท่านั้น หากได้มีสิทธิผูกพันกับจำเลยที่ 1 ไม่มีการที่โจทก์ชำระค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์เท่ากับเป็นการชำระแทนผู้เช่าเดิมและใช้โดยอาศัยสิทธิของผู้เช่าเดิมคือบริษัทสายการบิน ทีดับบลิว เอ จำกัด ทั้งนี้เพราะสัญญาเช่าโทรศัพท์ระหว่างบริษัทดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 ยังมีได้เลิกกัน และโจทก์ยังไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 1 ให้เป็นผู้เช่าโทรศัพท์แทนบริษัทดังกล่าว และข้อเท็จจริงปรากฏชัดและฟังได้ว่าตั้งแต่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาให้บริษัทสายการบินดังกล่าวเป็นผู้เช่าโทรศัพท์ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 8 เป็นต้นมา จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือติดต่อและแจ้งเก็บเงินค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์กับผู้เช่าตลอดมา หากได้มีเอกสารติดต่อกับโจทก์โดยตรงไม่ แม้แต่ค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ที่จำเลยที่ 3 ตรวจพบว่ามีการค้างชำระประจำเดือนมีนาคม 2527 แล้วจำเลยที่ 3 ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้นำเงินไปชำระตามเอกสารหมายเลข 3 และ 9 (แผ่นที่ 2) ก็ตาม มีข้อความเป็นตัวอักษรในหนังสือเอกสารดังกล่าวชัดแจ้งว่าบริษัทสายการบินทีดับบลิว เอ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เช่า หากใช้หนังสือไปถึงโจทก์ไม่ แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยังคงถือว่าบริษัทสายการบินดังกล่าวเป็นคู่สัญญาเช่าโทรศัพท์เครื่องพิพาทกับจำเลยที่ 1 ตลอดมา จึงฟังไม่ได้ว่า โจทก์มีนิติสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้หรือครอบครองโทรศัพท์กับจำเลยที่ 1 แต่ประการใดฉะนั้น การที่โจทก์อ้างว่าเป็นละเมิดต่อโจทก์เพราะไม่แจ้งให้โจทก์ทราบก่อนปลดฟิวส์ โจทก์มีสิทธินัดคดีมาฟ้องจึงรับฟังไม่ได้ทั้งเมื่อโจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 ก็ไม่ต้องแจ้งให้โจทก์ทราบไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น และที่โจทก์อ้างว่า จำเลยที่ 3 ไม่ได้ส่งเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งเป็นใบแจ้งเตือนให้ผู้เช่า

นำเงินไปชำระค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ตามที่อยู่ของผู้เช่านั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสามมีหลักฐานเป็นซองจดหมายใส่เอกสารและได้เจ้าหน้าที่ของถึงที่อยู่ของผู้เช่าซึ่งได้ให้ไว้ตรงตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 8 จัดแจ้งแล้ว ประกอบกับนายแสวง วรรณจู ซึ่งเป็นพยานของโจทก์เองเบิกความยืนยันว่าซองเอกสารหมายเลข 3 ส่งให้ผู้รับไม่ได้ พยานจึงลงชื่อไว้บนซองแสดงว่าจำเลยที่ 3 ได้ส่งใบแจ้งเตือนให้ผู้เช่านำเงินไปชำระค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ประจำเดือนมีนาคม 2527 ที่ค้างชำระอยู่แก่จำเลยที่ 1 แล้ว แม้โจทก์จะไม่ทราบก็ตามก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้โจทก์ทราบดังที่วินิจฉัยข้างต้น ฉะนั้นเมื่อครบกำหนดตามใบแจ้งเตือนแล้วผู้เช่ายังไม่นำเงินค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ไปชำระ การที่จำเลยที่ 3 ขออนุมัติและทำการปลดฟิวส์ย้อมถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้กระทำการตามหน้าที่และตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ 1 ว่าด้วยการงดให้บริการแก่ผู้เช่าโทรศัพท์ที่ค้างชำระค่าบริการ พ.ศ. 2526 ตามเอกสารหมายเลข 30 แล้วการกระทำของจำเลยที่ 3 ได้กระทำไปโดยสุจริตไม่ผิดระเบียบของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสามจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์โดยไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกต่อไป ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงบุญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ปัญหาที่ควรเข้าใจให้ดีในกรณีละเมิดเกี่ยวกับสัญญาคือสัญญาเป็นสิทธิอันหนึ่งซึ่งอาจถูกละเมิดได้เช่นเดียวกับสิทธิอื่น ๆ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จึงใช้คำว่าทำให้เสียหายต่อสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็เป็นละเมิด เช่นกรณีนี้ สิทธิของโจทก์ที่จะใช้โทรศัพท์คงต้องยอมรับว่ามีอยู่แน่แม้จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้โอนจากผู้เช่าโทรศัพท์เดิมมาเป็นชื่อโจทก์ก็จริง เช่น การเช่าบ้าน แม้จะเช่าบ้าน โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ให้เช่า การที่ผู้เช่าคนใหม่เข้าอยู่ในบ้านก็คงเป็นสิทธิอันหนึ่งของเขาที่เข้าครอบครองบ้าน แม้จะไม่ชอบด้วยกฎหมายอ้างยันเจ้าของผู้ให้เช่าไม่ได้ก็จริง แม้แต่ผู้บุกรุกก็ยังมีสิทธิครอบครองดีกว่าผู้ที่มารบกวนภายหลัง ขโมยมีสิทธิดีกว่าขะมาย เหตุนี้ที่คำกล่าวที่ว่าฟ้องฐานละเมิดอาจเกิดได้ทั้งกรณีที่มีสัญญาและไม่มีสัญญานั้น คงเข้าใจว่าไม่ต้องอาศัยสัญญาก็เป็นละเมิดได้ ซึ่งแท้จริงแล้วถ้าเป็นกรณีที่ต้องอาศัยนิติสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตามสัญญา จะฟ้องว่าทำผิดสัญญาจึงเป็นละเมิดและฟ้องทางละเมิดมิได้ ถ้าฟ้องทางละเมิดก็ต้องไม่อาศัยสัญญา เช่น ผู้เช่าทำให้ทรัพย์สินที่เช่าเสียหาย ถ้าจะฟ้องทางละเมิดก็อาจทำได้โดยไม่อาศัยหนี้ของผู้เช่าตามสัญญาคือต้องเป็นการทำต่อทรัพย์สินโดยพฤติการณ์ที่เป็นละเมิดได้แม้ไม่มีสัญญาก็ตาม ข้อที่ว่าโจทก์ต้องเป็นผู้เสียหายตามนิตินัยจึงจะฟ้องฐานละเมิดได้ไม่เพียงแต่เสียหายทางพจนินัยเท่านั้น ไม่เห็นมีหลักเช่นนี้ในมาตรา 420 คงเป็นปัญหาจริง ๆ ในเรื่องจำเลยทำละเมิดในกรณีนั้นหรือไม่เท่านั้น เรื่องนี้ผู้ปลดพิวส์ไม่ให้โจทก์ใช้โทรศัพท์เป็นเจ้าของโทรศัพท์ ถ้าคนอื่นปลดพิวส์คงไม่ต้องพิจารณาว่าโจทก์เสียหายโดยนิตินัยหรือไม่ โจทก์ถือว่าคนที่บังอาจมาปลดพิวส์ไม่ให้โจทก์ได้ใช้โทรศัพท์ทำละเมิดต่อโจทก์ได้ แม้โจทก์ยังมิได้รับอนุญาตเข้าเป็นผู้ใช้โทรศัพท์จากจำเลยก็ตาม เรื่องนี้จำเลยเจ้าของโทรศัพท์เป็นผู้ปลดพิวส์ จึงต้องพิจารณาว่าจำเลยมีอำนาจทำเช่นนั้นหรือไม่ โจทก์จึงฟ้องในฐาน

ละเมิด เพราะโจทก์ถือว่าโจทก์ยังไม่มีสัญญากับจำเลย จำเลยก็ไม่ถือว่ามีความสัญญากับโจทก์แล้ว จำเลยเป็นเจ้าของโทรศัพท์ยังมีสิทธิทำต่อทรัพย์สินของตนได้ โจทก์ก็คงยอมรับว่าจำเลยมีสิทธิเช่นนั้น จึงฟ้องว่าจำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เป็นการรับรองสิทธิของโจทก์ แต่อ้างว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จึงเป็นละเมิดต่อโจทก์ตามมาตรา 5 และมาตรา 421 ปัญหาข้อนี้คงมีคำตอบอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า มาตรา 421 นั้นต้องเป็นการกระซึ่ง"มีแต่จะทำให้เกิดความเสียหาย" แต่ถ้อยคำเดียว ถ้าจำเลยทำตามสิทธิของตนเพื่อประสงค์อย่างหนึ่งมิใช่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แต่ถ้อยคำเดียวแล้ว ก็ไม่เป็นละเมิด ผู้ที่ได้รับสัมปทานหรือผูกขาด มีข้อผูกพันที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชน เช่นรถโดยสารประจำทางจะปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารไม่ได้ ถือว่ารถที่วิ่งอยู่เป็นผู้ทำคำเสนอ ผู้โดยสารเป็นผู้ทำคำสนอง ผู้โดยสารที่ไม่ชำระค่าโดยสารตามอัตราจะถูกบังคับให้ลงจากรถในที่ ๆ ไม่สมควรได้หรือไม่ ผู้เข้าบ้านที่ผิดสัญญาเช่าจะถูกบังคับให้ออกจากบ้านเช่าโดยวิธีการอันไม่ปกติ เช่นตัดน้ำตัดไฟหรือปิดประตูไม่ให้เข้าบ้านได้หรือไม่ คงเป็นกรณีที่จะเทียบเคียงกับคดีนี้ได้ เหล่านี้เป็นกรณีสืบเนื่องจากสัญญาจะเป็นละเมิดหรือไม่ หรือเป็นกรณีที่เป็นการใช้สิทธิภายหลังที่สัญญารับลงแล้วอันเป็นผลของการเลิกสัญญาประการหนึ่ง จิตติ